

Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT

Nummer 7130/215

Betreft zaak: Taxivervoer IJsselsteden de heer D

Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 62 van de Mededingingswet.

I. Inleiding

1. Op 28 april 2011 heeft de Directie Mededinging van de Nederlandse Mededingingsautoriteit aan Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V. (hierna: RMC) en IJsselsteden Beheers Groep B.V. (hierna: IJsselsteden) rapporten in zaak 7130 toegezonden wegens het vermoeden van het overtreden van de Mededingingswet (Mw) door deze ondernemingen.
2. Dezelfde rapporten zijn ook gezonden naar de natuurlijke personen van wie werd vermoed dat zij feitelijk leiding hebben gegeven aan de overtredingen, onder wie de heer [vertrouwelijk] (hierna: de heer [D]) en in e-mails ook [vertrouwelijk] van IJsselsteden.
3. Dit besluit betreft de heer [D], [leidinggevende] van IJsselsteden.
4. Bijlage 1 bevat het besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad), kenmerk 7130/153, in welk besluit de Raad heeft vastgesteld dat IJsselsteden en RMC in van periode 18 december 2007 tot en met 27 augustus 2010 artikel 6 Mw hebben overtreden. Deze bijlage, inclusief de daarin gedefinieerde termen, maakt integraal onderdeel uit van dit besluit.

II. Juridisch kader

5. Artikel 56 Mw luidt, voor zover van belang, als volgt:
 1. Ingeval van overtreding van artikel 6, eerste lid (...), kan de raad de overtreder:
 - a. een bestuurlijke boete opleggen;(...).

6. Artikel 5:1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) luidt als volgt:

(...)

3. Overtredingen kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. Artikel 51, tweede en derde lid, van het Wetboek van Strafrecht is van overeenkomstige toepassing.

7. Artikel 51, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) luidt als volgt:

2. Indien een strafbaar feit wordt begaan door een rechtspersoon, kan de strafvervolgning worden ingesteld en kunnen de in de wet voorziene straffen en maatregelen, indien zij daarvoor in aanmerking komen, worden uitgesproken:

1. tegen die rechtspersoon, dan wel
2. tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede tegen hen die feitelijke leiding hebben gegeven aan de verboden gedraging, dan wel
3. tegen de onder 1° en 2° genoemden tezamen.

8. Een natuurlijke persoon kan beboetbaar leiding geven aan een overtreding van een onderneming of ondernemersvereniging door actieve gedragingen, waarbij de overtreding door hem wordt bevorderd door middel van handelen, alsook door passieve gedragingen, waarbij de natuurlijke persoon de overtredingen doet bevorderen door nalaten.¹
9. Uit de jurisprudentie volgen minimumcriteria wanneer in ieder geval sprake is van leiding geven in de zin van 51 Sr:

“Van feitelijk leiding geven aan verboden gedragingen kan onder omstandigheden sprake zijn indien de desbetreffende functionaris — hoewel daartoe bevoegd en redelijkerwijs gehouden — maatregelen ter voorkoming van deze gedragingen achterwege laat en bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de verboden gedragingen zich zullen voordoen. In deze situatie wordt de zojuist bedoelde functionaris geacht opzettelijk de verboden gedragingen te bevorderen”.²

10. De verplichting om maatregelen te nemen ter voorkoming van een bepaalde gedraging, kan op meerdere natuurlijke personen tegelijkertijd rusten.³ In zo een geval kan aan één gedraging van de rechtspersoon door meerdere personen tegelijkertijd leiding worden gegeven.

¹ Vergelijk Hoge Raad 20 november 1984, NJ 1985, 355. Zie ook recentelijk Rechtbank Rotterdam 16 mei 2012, LJN: BW 6221.

² Hoge Raad 16 december 1986, NJ 1987, 321 (*Slavenburg II*), r.o. 5.1.1.

³ Hoge Raad 16 juni 1981, NJ 1981, 586 (*Papa Blanca*), r.o. 8.

11. Het leidinggeven vereist volgens vaste jurisprudentie dat sprake is van (voorwaardelijk) opzet. Daartoe is in het geval van een overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw voldoende dat sprake is van opzet op de gedragingen van de onderneming.⁴ Niet van belang is of degene die kennis heeft van de gedragingen *beoogt* een norm te overtreden. Een dergelijke verzwaarde vorm van opzet is niet vereist.⁵
12. De Raad heeft in zijn besluit met kenmerk 7130/153 geconcludeerd dat de IJsselsteden artikel 6, eerste lid, Mw heeft overtreden. In het onderhavige besluit is aan de orde of de heer [D] daaraan feitelijk leiding heeft gegeven als bedoeld in artikel 5:1, derde lid, van de Awb, gelezen in samenhang met artikel 51, tweede lid, Sr.⁶

III. Feiten en omstandigheden

13. De Raad stelt in aanvulling op het sanctiebesluit met kenmerk 7130/153, waarin een overtreding van artikel 6 Mw door IJsselsteden is vastgesteld (bijlage 1), de navolgende feiten en omstandigheden vast.
14. De heer [D] is vanaf 22 december 2006 tot 27 augustus 2010 (deels via Ypsilon Beheer B.V.) [leidinggevende] bij IJsselsteden.⁷ De heer [D] is in de periode eind december 2007/januari 2008 tot ongeveer augustus 2008 [vertrouwelijk]. Hierover heeft hij als volgt verklaard:

“[vertrouwelijk]”.⁸

15. De Raad stelt vast dat de heer [D] direct betrokken is geweest bij de totstandkoming op 18 december 2007 van de afspraken die de basis vormen van de overtreding van IJsselsteden. Zo volgt uit een e-mail van 17 december van de heer [A] ([leidinggevende] van RMC) dat de heer [D] en de heer [C] (IJsselsteden) contact hebben met hem over de overeenkomst:

“Ik heb vanmiddag een vervolggesprek gehouden met IJsselsteden en alle onderwerpen doorgesproken, t/m aanbesteding VOM, etc. Ik wil dit verhaal morgenochtend doorsturen aan [C] en [D] en liefst die zelfde dag nog laten tekenen. Dus als het kan gaarne reactie voor 10:00 uur”.⁹

⁴ Hoge Raad 1 februari 2005, *NJ*2006, 421 (*SE Fireworks*), r.o. 7.5 en 7.6; Hoge Raad 12 januari 2010, *RvdW*2010, 168, r.o. 2.5.

⁵ Hoge Raad 18 maart 1952, *NJ*1952, 314, bevestigd in Hoge Raad 27 april 2007, *NJ*2007, 544, r.o. 3.3.

⁶ De Raad beschouwt opdracht geven als een bijzondere vorm van feitelijk leidinggeven en volstaat derhalve met de algemene term “leidinggeven”.

⁷ Dossierstuk 56, prisma-nummer 7130_43.

⁸ Dossierstuk 16, met kenmerk 7130_16: verklaring de heer [D] p. 4.

⁹ Dossierstuk 59, prisma-nummer 7130_41, bijlage 2.

16. Vervolgens hebben de heren [C] en [D] op 18 december 2007 meerdere malen contant met de heer [A] om tot in detail overeenstemming te bereiken over de afspraken.

“vertrouwelijk], vertrouwelijk], [NMa: de heren [C] en [D]]

Hierbij de versie die eigenlijk aan jullie had moeten versturen.

Deze heb ik aangepast op basis van mijn tel. Gesprekje met [vertrouwelijk].

Ik hoor graag verder van jullie.

Mvrgr.

[A]”.¹⁰

“Beste vertrouwelijk], vertrouwelijk], [NMa: de heren [C] en [D]]

Ik heb jullie laatste wens verwerkt in een extra alinea bij punt 9.

Tevens nog even een enkele tekstfout (o.a bij de tenaamstelling) verbeterd.

Als jullie morgen laten weten of we er dan zoals verwacht definitief uit zijn, dan is het voor ons allen misschien leuk om nog voor de Kerst te tekenen.

Mvrgr.

[A]”.¹¹

17. Hierna heeft de heer [D] de samenwerkingsovereenkomst met RMC van 18 december 2007 in zijn hoedanigheid als [leidinggevende] van IJsselsteden ondertekend.¹²
18. De heer [D] heeft zelf overigens bevestigd dat hij betrokken is geweest bij de totstandkoming van de overeenkomst.¹³
19. De heer [D] is tevens betrokken geweest bij de uitvoering van de afspraken tussen RMC en IJsselsteden inzake de aanbestedingen in de periode 18 december 2007 tot en met 27 augustus 2010. De Raad leidt dit af uit het volgende.
20. Op 16 april 2009 stuurt de heer [D], ook namens de heer [C], een e-mail aan de heer [A] over de aanbesteding van Vervoer op Maat 2008 (VOM). Hieruit volgt de betrokkenheid van de heer [D] bij de uitvoering van de verboden afspraken.¹⁴

“Goedemiddag vertrouwelijk], [NMa: de heer [A]]

¹⁰ Dossierstuk 59, met kenmerk 7130_41, bijlage 4.

¹¹ Dossierstuk 59, met kenmerk 7130_41, bijlage 5.

¹² Dossierstuk 60, met kenmerk 7130_42, bijlage 1.

¹³ Dossierstuk 16, met kenmerk 7130_16: verklaring de heer [D], p. 5 en 6.

¹⁴ Dossierstuk 59, met kenmerk 7130_41, bijlage 12.

Tot op dit moment hebben wij nog geen enkel teken van leven gezien van de kant van Connexxion aangaande het Achmea Zittend Ziekenvervoer in Rotterdam. (..) Dit impliceert dan wel dat wij, volgens afspraak, (Onderstropping NMa) per 1 mei a.s. mee gaan rijden met de afgesproken 10 voertuigen in het VOM project. Met wie of wanneer kunnen hier concrete afspraken over gemaakt worden?

Met groet,

[C]

[D]”

21. Hierop reageert RMC met de volgende e-mail:

“vertrouwelijk], vertrouwelijk], [NMa: de heren [C] en [D]]

Ik heb tijdens de opening van jullie schadeafdeling nadrukkelijk met vertrouwelijk] afgesproken dat de definitieve keuze nu gemaakt is en dat we nu niet meer gaan veranderen. Wij moeten immers naar de opdrachtgever VOM wel onze zaken voor elkaar hebben en wij hebben de uren en wagens inmiddels toebedeeld aan [vertrouwelijk].

(..)

Met vriendelijke groet,

[A]”

22. De heer [D] reageert hierop als volgt:

“Goedemorgen vertrouwelijk] [NMa: de heer [A]]

(..) Wij hebben begrip voor jullie situatie en begrijpen ook dat er, na wisselingen van de wacht aan de Keenstraat¹⁵, veranderingen zijn ontstaan. Deze veranderingen kunnen er volgens ons echter niet toe leiden dat wij met lege handen achter blijven. Volgens ons zijn wij de in jullie offerte met naam genoemde onderaannemer waarmee de RMC destijds op deze aanbesteding VoM heeft ingeschreven. Deze afspraak volgde destijds voort uit onze toezegging om niet zelf of in combinatie met een of meerdere andere partijen op dit project in te schrijven. Ook is de RMC schriftelijke contractuele afspraken met ons aangegaan om een (gedeelte) van het VoM project i.c.m. met de RMC uit te voeren.”(Onderstropping NMa)

23. Ook blijkt de betrokkenheid van de heer [D] bij de uitvoering van de overeenkomst uit het overleg dat hij voerde met de heer [A] over wie welke percelen gaat rijden bij het leerlingenvervoer in Krimpen. RMC en IJsselsteden hebben over deze aanbesteding op 8 maart 2010 onderling contact gehad. Dit blijkt uit een e-mail die de heer [D] zendt aan een medewerker van RMC over deze aanbesteding:

¹⁵ RMC en RTC zijn aan de Keenstraat in Rotterdam gevestigd.

*“Goedemiddag vertrouwelijk], [NMa: medewerker van RMC]
Contact gehad met vertrouwelijk] [NMa: de heer [A] inzake het LL-vervoer Krimpen. Kan jij
ons aangeven wat de ‘zuidelijke en de noordelijke routes’ zijn?
Met vriendelijke groet,
[D]
Ijsselsteden Taxi Combinatie B.V.”¹⁶*

24. De heer [A] koppelt het onderlinge contact als volgt terug in een interne e-mail:

*“Beste mensen,

Zojuist nog even gesproken met [C].
(...)
Afgesproken met vertrouwelijk] dat de RMC inschrijft op beide percelen. Ijsselsteden wordt
dan onderaannemer voor het noordelijk perceel en RMC rijdt zelf het zuidelijke perceel.
(...)”¹⁷*

25. Uit het bovenstaande volgt dat de heer [D] de wetenschap had van de afspraken die de overtreding van RMC en Ijsselsteden vormen. Naast de wetenschap volgt uit de feiten tevens dat de heer [D] direct betrokken is geweest bij de totstandkoming en de uitvoering van de verboden afspraken. Vast staat ook dat de heer [D] niets heeft gedaan om de verboden gedraging van RMC en Ijsselsteden te stoppen, hoewel hij hier als [leidinggevende] van Ijsselsteden toe bevoegd en gehouden was.

IV. Beoordeling

26. De Raad wijst erop dat hij in zijn besluiten met kenmerk 7130/153, heeft vastgesteld dat Ijsselsteden artikel 6 Mw heeft overtreden. In dit besluit heeft de Raad bovenstaande argument dat geen sprake zou zijn van mededingingsrechtelijk verboden gedragingen reeds behandeld en weerlegd. Met betrekking tot het feitelijk leidinggeven door de heer [D] oordeelt de Raad als volgt.
27. De heer [D] is in de periode 18 december 2007 tot en met 27 augustus 2010 [leidinggevende] van Ijsselsteden, in welke hoedanigheid hij leiding geeft aan de gehele onderneming Ijsselsteden. Hieruit vloeit voort dat de heer [D] medeverantwoordelijkheid heeft voor

¹⁶ Dossierstuk 59, met kenmerk 7130_41: bijlage 15.

¹⁷ Dossierstuk 59, met kenmerk 7130_41: bijlage 16.

[vertrouwelijk].

28. In zijn hoedanigheid als [leidinggevende] van IJsselsteden heeft de heer [D] bij uitstek de hiërarchische en feitelijke positie en de daarbij horende bevoegdheid om gedragingen die leiden tot de overtreding door de IJsselsteden te voorkomen, dan wel vervolgens na aanvang van de overtreding deze ongedaan te maken.
29. De Raad heeft in hoofdstuk 3 van dit besluit vastgesteld dat de heer [D] direct betrokken is geweest bij de totstandkoming van de afspraken die de overtreding van IJsselsteden vormen. De heer [D] heeft op 17 december 2007 persoonlijk de besprekingen met RMC gevoerd over de afspraken, zoals die zijn neergelegd in de overeenkomst van 18 december 2007, en die de basis van de overtreding van IJsselsteden. Daarbij heeft de heer [D] deze overeenkomst ondertekend.
30. Vervolgens stelt de Raad vast dat de heer [D] direct betrokken is geweest bij de uitvoering van de afspraken tussen RMC en IJsselsteden. De heer [D] heeft in zijn hoedanigheid als [leidinggevende], niet alleen afschriften van e-mailwisselingen tussen RMC en IJsselsteden ontvangen, ook is hij op de hoogte gehouden van de contacten tussen RMC en IJsselsteden. De heer [D] heeft daarnaast persoonlijk contact gehad met RMC over de uitvoering van de afspraken tussen RMC en IJsselsteden.
31. Naar het oordeel van de Raad staat daarmee vast dat de heer [D] de gedragingen van de onderneming IJsselsteden bewust heeft aanvaard.

Conclusie

32. De Raad stelt vast dat de heer [D] de gedragingen van IJsselsteden die in strijd zijn met de Mededingingswet niet heeft voorkomen, beëindigd of doen eindigen. Integendeel, hij is zelf direct betrokken is geweest bij die gedragingen en is ook betrokken geweest bij de uitvoering van de verboden afspraken. Vast staat ook dat de heer [D] zelf bevoegd en gehouden was een eind te maken aan de gedragingen van IJsselsteden die de Raad als overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw heeft gekwalificeerd, maar dit niet heeft gedaan.
33. Op grond van het handelen van de heer [D] en het nalaten de overtreding te beëindigen (waartoe hij als [leidinggevende] van IJsselsteden was gehouden), stelt de Raad vast dat de heer [D] voor de gehele duur van de overtreding van IJsselsteden, van 18 december 2007 tot en met 27 augustus 2010, hieraan leiding heeft gegeven.
34. In het licht van het voorgaande kan de heer [D] worden aangemerkt als overtreder in de zin van artikel 5:1, derde lid, Awb.

V. Sanctie

V.I. Beoordelingskader

35. Op grond van artikel 57, eerste lid, Mw, gelezen in samenhang met artikel 5:1, derde lid, Awb, kan de Raad, wanneer een overtreding gepleegd is door een rechtspersoon, een bestuurlijke boete van ten hoogste EUR 450.000 opleggen aan degenen die tot de overtreding opdracht hebben gegeven of daaraan feitelijk leiding hebben gegeven. De nadere invulling van de factoren waarmee bij de vaststelling van de hoogte van de boete rekening wordt gehouden, is aan de Raad overgelaten. Hierbij dient hij rekening te houden met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
36. Met betrekking tot de hoogte van een boete heeft de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) op grond van artikel 5d Mw beleidsregels vastgesteld om de Raad richting te geven bij de uitoefening van zijn bevoegdheid tot het opleggen van boetes. Omdat de overtreding na 1 oktober 2009 heeft voortgeduurd, zijn de Boetebeleidsregels van de Minister van Economische Zaken voor het opleggen van bestuurlijke boetes door de NMa 2009 ("Boetebeleidsregels") van toepassing.¹⁸
37. De Raad stelt op grond van artikel 11, tweede lid, van de Boetebeleidsregels een boetegrondslag vast die is gerelateerd aan de ernst van de overtreding en het inkomen en vermogen van de overtreder, teneinde tot een bestuurlijke boete te komen die zowel uit het oogpunt van algemene preventie als uit het oogpunt van specifieke preventie voldoende afschrikwekkend is. De boetegrondslag is de basisboete.
38. Ingevolge artikel 11, vierde lid, onderdeel b, van de Boetebeleidsregels wordt de boetegrondslag voor natuurlijke personen voor het feitelijk leiding geven aan een overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw vastgesteld binnen de bandbreedte van 50.000 - 400.000 euro. De boetegrondslag wordt binnen deze bandbreedte gerelateerd aan de ernst van de overtreding van zowel de rechtspersoon als de feitelijk leidinggever en de inkomens- en vermogenspositie van die feitelijk leidinggever. Voorts neemt de Raad bij de vaststelling van de bestuurlijke boete boeteverhogende en -verlagende omstandigheden in aanmerking.¹⁹

V.II. Toepassing

39. Onder verwijzing naar het besluit met kenmerk 7130/153 staat vast dat IJsselsteden zich schuldig heeft gemaakt aan zeer zware overtredingen waarvoor een ernstfactor van 3 is vastgesteld. Met betrekking tot de rol van de heer [D] als feitelijk leidinggever daaraan, overweegt de Raad als volgt.

¹⁸ Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken voor het opleggen van bestuurlijke boetes door de NMa 2009, *Stcrt.* 2009, nr. 14079.

¹⁹ Artikel 12 Boetebeleidsregels.

40. Met inachtneming van de ernst van de overtreding en in aanmerking nemende de financiële positie van de heer [D] stelt de Raad achtereenvolgens de boetegrondslag en de basisboete vast op EUR 1.000. Daarbij kent de Raad gewicht toe aan de positie die de heer [D] inneemt in de [vertrouwelijk] van IJsselsteden en aan zijn directe betrokkenheid bij de gedragingen die de overtreding van IJsselsteden vormen.
41. De Raad kan de basisboete nog bijstellen, wegens boeteverhogende of –verlagende omstandigheden. De Raad ziet in deze zaak geen aanleiding voor een boeteverhoging dan wel boeteverlaging.
42. Alles overwegende is de Raad van oordeel dat in dit geval een boete van EUR 1.000 voor het feitelijk leidinggeven door de heer [D] aan de overtreding van IJsselsteden zoals vastgesteld bij besluit met kenmerk 7130/153, passend is.

VI. Besluit

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit:

legt aan de heer [D], geboren op [vertrouwelijk] te [vertrouwelijk], een boete op van EUR 1000.

Datum: 20 november 2012

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
namens deze,

Wg.

Henk Don

Lid van de Raad van Bestuur

*Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.
In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.*